

1501210-22.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... é de que a casa era um ponto de tráfico. Ora, não se nota na assentada dos relatos qualquer outro momento de afastamento do discurso, mas a autoridade policial, neste aspecto, fez questão de frisar que o imóvel era um "ponto de tráfico, segundo os guardas municipais".

Por sua vez, na denúncia, não é mais o imóvel o tal ponto de tráfico, mas sim a rua, o que é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1501210-22.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501210-22.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAYARA APARECIDA DA SILVA LEME

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de NAYARA APARECIDA DA SILVA LEME, já qualificada nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 03 de novembro de 2021, por volta de 00h45min, na estrada Velha de Descalvado, altura do nº 1000, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, 48 pedras de "crack" com peso bruto de 47,0 gramas, 263 microtubos contendo "cocaína" com peso bruto de 541,0 gramas, 151 porções de "maconha" com peso bruto de 301,0 gramas; 34 microtubos contendo "maconha" com peso bruto de 55,0 gramas e 01 porção maior de "cocaína" com peso bruto de 55,0 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "guardas municipais se deslocavam pelo endereço acima declinado - uma notória rua onde se pratica de forma incessante o tráfico de drogas nesta comarca - quando ali avistaram a denunciada trazendo sob suas vestes um grande volume na região da cintura, a qual, ao notar a aproximação da viatura, alterou seu comportamento, apresentando nervosismo, o que envidou fundada suspeita nos agentes públicos acerca da possível ilicitude do objeto que carregava sob as vestes de forma dissimulada. Assim, diante

da fundada razão e urgência da medida para possível apreensão de objetos de natureza ilícita transportados em via pública, a denunciada foi abordada, ocasião em que apresentou aos agentes públicos duas pochetes que estavam presas em sua cintura sob a camiseta, as quais continham as porções de drogas acima mencionadas, todas fracionadas e prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de R\$ 21,35. Em audiência de custódia, devidamente advertida sobre a possibilidade de não falar sobre os fatos, a denunciada ainda assim quis se pronunciar, ocasião em que confessou a prática do tráfico, esclarecendo que estava na posse das duas pochetes com drogas quando foi abordada pelos agentes e que tentou sair correndo quando alertada por um outro indivíduo que gritou "moiou". Disse ainda que a abordagem se deu na rua, após sair do imóvel onde pegou as drogas com um rapaz. As circunstâncias e o local da prisão, a grande quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a confissão da denunciada perante o Juízo mesmo advertida demonstram, com segurança, que ela trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia não foi recebida por ausência de justa causa.

O representante Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito às fls. 319/327.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial em acórdão de fls. 387/392 determinando o recebimento da denúncia.

Foi apresentada defesa prévia às fls. 235/239, após a citação de fls. 255.

Foi realizada audiência de instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Com a devida vênia ao respeitável acórdão, transcorrida a instrução, é o caso de concluir pela absolvição em razão da ilicitude da prova colhida.

Nota-se, em verdade, um hercúleo esforço argumentativo da acusação para disfarçar a visível ilegalidade.

Diz a denúncia:

(...) guardas municipais se deslocavam pelo endereço acima declinado - uma notória rua onde se pratica de forma incessante o tráfico de drogas nesta comarca - quando ali avistaram a denunciada trazendo sob suas vestes um grande volume na região da cintura, a qual, ao notar a aproximação da viatura, alterou seu comportamento (...)

Segundo a inicial acusatória a decisão pela busca pessoal deu-se pela visualização de um volume embaixo das vestes da pessoa imputada e pelo fato de no local haver um ponto de venda de drogas.

Entretanto, o relato ministerial inverte a ordem dos fatos. Lê-se às fls. 03 do depoimento do guarda municipal Rodrigo Dresler (ou seja, anterior ao controle de constitucionalidade e legalidade feito pelo judiciário a partir da análise do auto de prisão em flagrante):

(...) que o depoente é Guarda Municipal em Porto Ferreira e, juntamente com o seu colega de serviço Eliseu, patrulhavam na Estrada Velha de Descalvado, momento em que avistaram uma mulher saindo de uma casa, a qual, segundo o depoente, é conhecido como ponto de venda de drogas; que, de imediato, o depoente verificou que referida mulher, ao ver a viatura, ficou nervosa, sendo que seu colega Eliseu já desembarcou e procedeu a abordagem; que neste interim, o depoente constatou que referida mulher apresentava um volume por baixo da camisa (...)

Como de pode bem perceber, a decisão dos guardas pela abordagem deu-se tão somente pelo fato de o local ser um ponto de tráfico e pelo nervosismo da pessoa imputada. O volume foi notado apenas durante o procedimento, tanto que a expressão utilizada foi "neste interim".

Isso fica ainda mais claro com a versão dada pelo guarda Eliseu Soares, responsável pela abordagem, às fls. 04:

(...) que o depoente, é Guarda Municipal nesta cidade e, na madrugada de hoje, juntamente com seu colega Dresler, efetuavam patrulhamento pelas imediações da Estrada Velha de Descalvado, momento em que foi avistado uma mulher saindo de uma casa; que referido local, segundo o depoente, é conhecido como ponto de venda de drogas; que referida mulher, ao ver a presença da viatura, ficou assustada, tendo o depoente desembarcado da viatura e procedida a abordagem; que, na abordagem, foi constatado que referida mulher apresentava um volume por baixo da camisa (...)

O que é realmente flagrante no caso é a constatação do volume após a decisão pela busca pessoal.

Além disso, a versão dada pelos guardas municipais perante a autoridade policial, que é o momento em que precisam justificar a diligência invasiva, é de que a casa era um ponto de tráfico. Ora, não se nota na assentada dos relatos qualquer outro momento de afastamento do discurso, mas a autoridade policial, neste aspecto, fez questão de frisar que o imóvel era um "ponto de tráfico, segundo os guardas municipais".

Por sua vez, na denúncia, não é mais o imóvel o tal ponto de tráfico, mas sim a rua, o que é infinitamente diferente e mais vago.

Raciocínios como esse, repito, com a devida vênia, é que legitimam abordagens indiscriminadas em regiões com intensa venda de entorpecentes. Ora, as pessoas trabalhadoras que lá vivem sofrem tanto com a maldição do comércio espúrio, que expõe seus filhos e parentes a verdadeiras tragédias familiares, como também com um poder ilimitado dado às forças policiais; contexto que facilita demasiadamente a prática de diversos e graves abusos.

Em audiência, pode-se constatar que no imóvel de número 1000 reside a Sra.

Rosineide com seu marido e seu filho especial. Nenhuma testemunha, seja de acusação ou de defesa, em juízo, apontou que na residência dela vende-se drogas.

Em alegações finais, nova oscilação da acusação, apontando agora que no número 1010 estaria o imóvel ligado ao ponto de tráfico.

Não se faz aqui um preciosismo na identificação geográfica da ocorrência, pois não se desconsidera que para algo que se passa na via pública, a imputação do numeral implica alguma imprecisão. A questão é que o guarda municipal disse que a sua suspeita estava ligada ao numeral 1000. Esse é o relato dele. Relato do qual se afastou verbalmente a autoridade policial civil e foi infirmado pela prova produzida pela defesa.

Tomar por lícito tal procedimento implica reconhecer a possibilidade de o estado realizar uma diligência invasiva de busca pessoal em um sujeito simplesmente pelo fato de haver suspeitas de que o vizinho dele seja traficante.

De fato, fazer isso em uma região urbana no qual as pessoas estão privadas de aspectos mínimos da existência humana pode até parecer razoável. Mas não se vê o mesmo comportamento do estado em regiões mais favorecidas economicamente. O que, infelizmente, revela uma ilegítima seletividade do estado policial. E o estado, que deveria ser um instrumento de igualdade entre cidadãos (conforme o texto constitucional vigente), mostra-se, em situações como essa, um propagador de desigualdades.

Os guardas justificaram a abordagem também em razão do "nervosismo" da pessoa imputada.

Tal argumento não tem sido aceito pela jurisprudência. Isso pode ser remontado ao item 4 do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) (aplicado por analogia):

(...) a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental

da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias (...)

Ou seja, para que a busca domiciliar e pessoal sem mandados judiciais seja válida, é necessário que os motivos alegados sejam "sindicáveis", isto é, passíveis de controle por parte da defesa.

Ora, qual defesa efetivamente cabe contra argumentos tais como o "nervosismo"? Não se trata de colocar sob dúvida a palavra do funcionário público, como a posição mais açodada leva a concluir. Trata-se tão somente de estabelecer um padrão pelo qual seja possível o controle da atividade policial, impedindo que tão nobre e essencial atividade seja confundida com o arbítrio.

Aliás, é como o STJ (tribunal responsável pela uniformização do direito processual penal no país conforme art. 105, inciso III, c.c. art. 22, inciso I, ambos da Constituição) recentemente se manifestou (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2º- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais (nervosismo ante a presença da autoridade policial e ingresso no interior do imóvel), sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão da droga e, consequentemente, trancar a ação penal n. 5014975-62.2021.8.24.0033 (art. 386, II - CPP), determinando a restituição da liberdade dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos.

HC 687342/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.

O Brasil é signatário da CADH, sendo a Corte IDH responsável pela sua interpretação autêntica, conforme a própria Convenção. Desnecessário aprofundar no mérito do recente Prieto & Tumbeiro vs. Argentina (entre outros pontos, a Corte IDH entendeu que a detenção baseada em alegado "nervosismo" por parte dos policiais está sujeita a uma subjetividade tal que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com a Convenção), sendo a confissão de culpa do estado argentino (o que afasta o argumento fácil de que o controle da atividade policial não pode ser feito em um país como o Brasil), por si só, suficiente (grifos nossos):

26. En su reconocimiento de responsabilidad internacional, suscrito el 4 de marzo de 2020, el Estado aceptó la totalidad de las conclusiones establecidas por la Comisión en su Informe de Fondo, lo cual incluye las concernientes a que las detenciones de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro se enmarcaron en un contexto general de detenciones practicadas sin orden judicial ni supuestos de flagrancia en Argentina. En el mismo orden, en su escrito de alegatos finales de 18 de junio de 2020, el Estado reconoció que este "caso constituye un emblema de lo que se conoció en nuestro país, durante la década del 90, como el 'olfato policial', que implicaba actuaciones policiales descontroladas, incentivadas por políticas de seguridad pública basadas en operativos de prevención discrecionales, sin investigación ni inteligencia previa, y por ello, profundamente ineficientes". Asimismo, el Estado puntualizó que "este tipo de prácticas policiales fueron promovidas por políticas de seguridad que se definían bajo el paradigma de la llamada 'guerra contra las drogas' y que, además, resultaban amparadas por un inadecuado o inexistente control judicial"

Vê-se, assim, que a diligência invasiva calçou-se apenas nas percepções subjetivas dos guardas, quando, em verdade, a lei exige uma suspeita fundada, qualificada. A lei exige "fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".

É necessário que o agente de segurança pública (a Constituição nos incisos de I a VI no art. 144 delimita quem são os órgãos de segurança pública) aponte uma circunstância objetiva que o levou a antever com considerável probabilidade que a pessoa-alvo estivesse na posse de arma ou objetos que constituíssem corpo de delito. É necessário que o agente de segurança decline do que suspeitava (se era a posse de arma ou de outro objeto – sendo necessário citar este outro objeto). O nervosismo, por ser extremamente subjetivo, não é justificativa aceita; o fato de tão só estar em local conhecido como ponto de tráfico, tampouco, exigindo, no mínimo, que o agente de segurança, p. ex., notasse uma presença excessivamente prolongada da pessoa imputada no local, uma posição de venda (ou de divisão de tarefas na venda) etc. Ou seja, circunstâncias compatíveis com a traficância que permitissem legitimamente inferir a probabilidade desta pessoa estar na posse de drogas. Sem estas exigências, seria lícita qualquer busca pessoal, p. ex., nos moradores da referida rua [justamente o argumento da acusação] que estivessem se dirigindo às suas casas [mesmo quando a suspeita recaísse sobre o vizinho]], o que é absolutamente incompatível com a proteção constitucional da intimidade. No caso, os guardas não disseram qual era essa "atitude suspeita", se a pessoa imputada estava pelo local havia horas, se foi vista fazendo gestos compatíveis com a venda em ponto de venda de drogas etc. Nada. Apenas disseram que a pessoa imputada demonstrou nervosismo.

Ora, se o padrão exigido pela lei (art. 244 do Código de Processo Penal) para busca pessoal sem mandado é justamente a "fundada suspeita", aceitar como justificativa para a diligência invasiva a tão só declinação pelo agente de segurança pública de termo idêntico ou extremamente similar ("atitude suspeita") implica abdicar de qualquer controle da atividade policial.

Por fim, a atuação dos guardas municipais enquanto tais.

Dando o devido respeito ao texto constitucional, as guardas municipais tem por função a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios (§8º do art. 144). Seus agentes tem, enquanto "qualquer do povo", a faculdade de dar voz de prisão quando encontrarem alguém em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal).

Mas não possuem qualquer atribuição para proceder a diligências invasivas que levem ao desvendamento de infração que esteja fora do âmbito de atribuição de sua corporação..

O art. 37 da Constituição impõe a toda a administração o respeito ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Aliás, para as guardas municipais esta exigência está expressa na parte final do §8º do art. 144.

Eis o que dispõe a lei complementar local de n.º 179, de 28 de novembro de 2017, com redação praticamente idêntica ao texto da Lei (federal) 13.022/2014 (grifos nossos):

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São princípios, básicos, da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira aqueles elencados na Lei Federal nº 13.022/14.

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força.

VI - compromisso com os princípios que regem a administração pública e respeito ao Estado Democrático de Direito.

Art. 4º É competência geral da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira a proteção dos bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais e proteção às pessoas em todo Município, nos termos do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências, específicas, da Guarda Civil Municipal; respeitadas as competências dos órgãos Federais e Estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer nas vias e logradouros municipais a fiscalização de trânsito, lavrar autuações e aplicar medidas administrativas, pelas infrações de circulação, parada e estacionamento, nos termos do art. 24 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, por meio da celebração de convênios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme Plano Diretor Municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários;

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de Segurança Pública da União e do Estado, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV, deste artigo; diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição

Federal, deverá a Guarda Civil Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Art. 6º É considerado serviço próprio do Guarda Civil Municipal, para todos os efeitos legais, inclusive a arregimentação, o exercício em cargo ou funções de natureza de segurança, bem como os de ensino e aprendizagem nos assuntos da área de sua atuação.

Art. 7º A Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira será custeada com recursos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual, além de subvenções, donativos e contribuições.

Ora, partindo do princípio da legalidade, o máximo que podem os guardas municipais locais é "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário". Não há qualquer autorização para diante de suspeitas de flagrantes de delitos que estejam fora do domínio material de vigência das atribuições das GCMs proceder a medidas invasivas.

É preciso aqui fazer um alerta contra o argumento fácil e tentador de "quem pode o mais (prender), pode o menos (busca pessoal)". Como a decisão com base em valores abstratos exige a ponderação das consequências práticas (art. 20 do Decreto-Lei 4.657/42), é inevitável reconhecer que a prisão é o ato de polícia máximo, razão pela qual este raciocínio é inválido por legitimar uma verdadeira equiparação das guardas municipais às polícias, conferindo a elas um poder de polícia completo. Mais. Não se pode desconsiderar a interpretação sistemática do feixe de atribuições instituído pelo constituinte no art. 144, o qual confere às polícias militares a função da patrulhamento ostensivo. De forma que as diligências preventivas, com as exceções expressas da constituição para a polícia federal (tráfico, contrabando e descaminho, policiamento marítimo, portuário e de fronteiras) e as guardas municipais (bens, serviços e instalações municipais), cabem tão somente às PMs. Vale ressaltar que é exatamente nesse sentido o entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei municipal 13.866/06 que fixava, dentre as atribuições da guarda municipal da capital, "exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos", assim entendeu o órgão máximo do tribunal. Confira-se a ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana – Art. 147 da Constituição Estadual – Proteção dos bens, serviços e instalações municipais – Matéria debatida é atinente à segurança pública – Preservação da ordem pública – Competência das polícias, no âmbito do Estado – Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais – Extrapolação dos limites constitucionais – Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. (ADI nº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 10/12/2008).

Trata-se, como se percebe, de entendimento consolidado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 5.626, de 16 de abril de 2018, do Município de Valinhos, que assegurou à Guarda Municipal a identificação como 'Polícia Municipal de Valinhos' - Alegação do Prefeito, autor da ação, de usurpação da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar matéria sobre a organização dos serviços públicos municipais, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à nova designação da Guarda Municipal - Matéria claramente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação dos artigos 5º, 24, § 2º, item 4, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144 – Incidência, ainda, do preceito do artigo 147 da Carta Bandeirante, que reproduz o texto do artigo 144, § 8º, da CF/88, que estabelece que a guarda municipal é força de natureza civil destinada à

proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União - Inconstitucionalidade das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil - Não violação, por outro lado, dos preceitos orçamentários, segundo Tema 917, em repercussão Geral, no S.T.F. - Ação julgada procedente.

TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286983-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020.

É essa também a lição da doutrina constitucionalista.

José Afonso da Silva (Comentário Contextual à Constituição, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638/639) assevera que:

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, §4º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais.

Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, v. 5, p. 246) observa que:

A Constituição de 1988 atribuiu às Guardas Municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º), não as fazendo auxiliares da Polícia Militar nem lhes conferindo função repressiva dos crimes.

Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini (Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini, Guarda Municipal - Criação e Implantação - Constituição Federal - Constituição Estadual - Lei Orgânica do Município, in Boletim de Direito Municipal, ano IV, nº 3, pág. 203) também destacam que às guardas municipais “não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil”.

Não diverge a melhor doutrina processual penal.

Gustavo Badaró (Processo Penal, 3ªed, 2015, p. 496), professor titular de Direito Processual Penal da USP, afirma que:

(...) há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes.

O Desembargador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal comentado, 2017), por sua vez, ensina:

Agentes autorizados a realizar busca pessoal: são os que possuem a função constitucional de garantir a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária

federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 144, CF). Não possuem tal função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal. Naturalmente, se um flagrante ocorrer, podem prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, como seria permitido a qualquer do povo que o fizesse, apresentando o infrator à autoridade policial competente.

Enfim, qualquer que seja o caminho argumentativo, não podem os membros das guardas municipais proceder à qualquer diligência invasiva para apurar delito que não tenha qualquer correlação com a proteção bens, serviços ou instalações municipais.

Ora, se mesmo quando diante de flagrante delito, cabe a eles somente encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia, por qual razão poderiam proceder à busca pessoal se sequer sabiam se a pessoa acusada encontrava-se nessa situação?

Se tinham fundadas suspeitas de cometimento de crime grave (equiparado a hediondo) por parte da pessoa imputada, deveriam ter, em respeito ao texto constitucional, comunicado à Polícia Militar e/ou Civil para que tomassem as medidas necessárias. Vale ressaltar que na fase policial nenhum dos guardas municipais justificou a relação entre a diligência e o âmbito de atribuições da corporação. Em juízo, o GCM Eliseu nada falou; já o GCM Rodrigo disse que no bairro há alguns patrimônios públicos.

Com a devida vênia, se a Constituição rejeitou às guardas municipais a condição de órgão de segurança pública; se a Constituição limitou a atuação das GCMs à proteção de bens, serviços e instalações municipais; legitimar a ação da GCM em qualquer bairro que tenha equipamento qualquer público municipal equivale a ignorar a decisão do constituinte de, expressamente não colocar as guardas municipais nos incisos do topo do art. 144.

Em âmbito legal, a guarda municipal compõe o Sistema Único de Segurança Pública (§1º, inciso VII, do art. 9º da Lei 13.675/18. E mesmo no âmbito das operações combinadas do SUSP, as guardas só podem, e sequer seria constitucional algo diferente, participar nos limites de sua competência (§2º do art. 10).

E no caso sequer se tratava de operação combinada, vale dizer.

Tendo sido a prova da suposta infração penal obtida por meio ilícito, o que não é admitido conforme clara determinação constitucional (inciso LVI do art. 5º), impossível a procedência do pedido condenatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER NAYARA APARECIDA DA SILVA LEME das acusações a ela imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 19 de agosto de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA